InDret

Responsabilidad civil por la privación de la posibilidad de abortar (wrongful birth)

Comentario a la STS, 1ª, 18.12.2003

Miquel Martín Casals
Josep Solé Feliu
Universitat de Girona

Working Paper nº: 217
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

Sumario

1. Los hechos de la STS 18.12.2003
2. El contexto jurisprudencial
3. El fundamento de las demandas de *wrongful birth* . La imposibilidad de decidir sobre la interrupción legal del embarazo
4. El segundo fundamento de responsabilidad en la sentencia de 18.12.2003. Un fundamento subsidiario de las acciones de *wrongful birth*
5. La relación de causalidad
6. El daño indemnizable en las demandas de *wrongful birth*
7. Tabla de Sentencias Citadas
8. Bibliografía

1. Los hechos de la STS 18.12.2003

El 20 de junio de 1993, Dolores G. dio a luz a un niño con unas graves malformaciones congénitas que los médicos especialistas no habían detectado a pesar de haberle practicado cuatro ecografías durante el embarazo.

La primera, practicada por la Dra. Carreras a las veinte semanas y tres días de la gestación, ya aportó indicios para sospechar que faltaba en el feto una de las dos arterias, origen de las malformaciones. Por ello, la Dra. aconsejó efectuar una nueva ecografía dos o tres semanas después. Esa segunda ecografía la practicó el Dr. Gisbert quien, según quedó reflejado en el informe correspondiente, no detectó anomalía alguna en las arterias ni malformaciones en las extremidades. No obstante, la gestante todavía se sometió a dos ecografías más.

La tercera ecografía, que le fue practicada por la citada Dra. Carreras y por el Dr. Gómez, tuvo lugar entre las 32 y 33 semanas de gestación, es decir, cuando ya había transcurrido sobradamente el plazo de veintidós semanas que exige la ley para interrumpir legalmente el embarazo por causa de las "graves taras físicas o psíquicas del feto" (Cf. art. 417.bis CP-1973). En el informe que acompañaba esa ecografía se indicaba que era probable que existiera una "arteria umbilical única", lo que, sin embargo, no dio lugar a que se llevara a cabo ningún examen anatómico del feto. La cuarta ecografía, finalmente, se practicó el día anterior al parto. En el informe correspondiente se indicaba que los datos anatómicos relativos a la cabeza, tórax y abdomen eran normales y, sin hacer mención de los relativos a las extremidades, se reiteraba simplemente la probable existencia de una "arteria umbilical única". Al día siguiente se produjo el nacimiento de un niño que presentaba graves malformaciones físicas, entre las que se encontraban la ausencia de riñón izquierdo y de extremidad inferior izquierda.

Los progenitores, en nombre propio y como representantes legales de su hijo, interpusieron una demanda de responsabilidad civil contra el ginecólogo, los tres especialistas ecógrafos, y contra el Hospital Universitario Materno Infantil Valle de Hebrón, el Institut Català de la Salut y la Compañía de Seguros Winterthur, en la que reclamaron una indemnización de 150.000.000 PTA por los daños y perjuicios causados. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona, estimó parcialmente la demanda y condenó a los demandados a pagar 25.000.000 PTA. Aunque la Audiencia Provincial de Barcelona les absolvió a todos, la STS 18.12.2003 [*Diario La Ley nº 5938,* jueves, 22 de enero de 2004] estimó el recurso de casación interpuesto por los progenitores y, si bien absolvió al ginecólogo, condenó al resto de los codemandados a pagar una indemnización de 60.000.000 PTA (aprox. 360.000 €).

2. El contexto jurisprudencial

La STS 18.12.2003 constituye la cuarta ocasión en que el Alto Tribunal se pronuncia sobre un supuesto de *wrongful birth* y, al parecer, recupera alguno de los aspectos que ya se habían apuntado en la primera sentencia que dictó sobre la materia (STS 6.6.1997 [RJ 1997\4610]).

Además, al conceder una indemnización por los daños morales y los perjuicios económicos que derivan del nacimiento del hijo con malformaciones, rompe con la tendencia a no indemnizar estos casos que parecían apuntar las SSTS 4.2.1999 [RJ 1999\748] y 7.6.2002 [RJ 2002\5216].

La primera sentencia, dictada por el Tribunal Supremo en la materia (STS 6.6.1997 [RJ 1997\4610]), se refería a una embarazada que se había sometido a una amniocentesis en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, dependiente del Servicio Valenciano de Salud. La prueba resultó fallida, pero se le comunicó esa circunstancia dos meses más tarde, momento en el que ya había transcurrido el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo. La gestante tuvo un hijo con síndrome de Down e interpuso demanda de responsabilidad civil contra el médico que practicó la prueba, contra el médico sustituto, y contra el Servicio Valenciano de Salud, en la que solicitaba una indemnización de 50 millones de PTA (aproximadamente € 300.000). Aunque el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Valencia desestimaron la demanda, el Tribunal Supremo la acogió y condenó solidariamente al Servicio Valenciano de Salud y a la doctora sustituta a pagar la indemnización reclamada en concepto de daños morales y materiales.

A un resultado diametralmente opuesto llegó la STS 4.2.1999 [RJ 1999\748], relativa a una mujer que dio a luz una hija con diversas anomalías congénitas y a la que durante el embarazo se le practicaron las ecografías requeridas por un embarazo de bajo riesgo como, al parecer, era el suyo. Ninguna de ellas detectó que el feto padeciera anomalías de tipo alguno. Tras el parto, los padres demandaron a la ginecóloga que había hecho el seguimiento del embarazo, así como a la delegación provincial del Insalud y al Ministerio de Sanidad y Consumo. Los progenitores reclamaban una indemnización de 200.000.000 PTA (aproximadamente € 1,2 millones) con el argumento de que la falta de información sobre las anomalías les había impedido optar por interrumpir voluntariamente el embarazo. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y condenó al Insalud a pagar una indemnización de 75 millones de PTA (aprox. € 450.000), pero la Audiencia Provincial de Salamanca estimó el recurso de apelación y absolvió a los demandados. El Tribunal Supremo confirmó el criterio de la Audiencia y mantuvo la absolución de todos los demandados.

La tercera sentencia (STS 7.6.2002 [RJ 2002\5216]), de nuevo relativa al nacimiento de un hijo con síndrome de Down, confirmó la línea iniciada por la anterior. La madre, una mujer de 40 años y con tres hijos, había sufrido un aborto espontáneo algunos meses antes de quedar embarazada. Por ello, durante el embarazo, tanto ella como su esposo manifestaron repetidas veces al ginecólogo su temor por haber engendrado un hijo con alguna anomalía. A pesar de esa insistencia, el ginecólogo se limitó a tranquilizarles afirmando repetidamente que "todo iba normal". Tras el nacimiento, los padres interpusieron una demanda de responsabilidad civil, en nombre propio, en nombre y representación de sus tres primeros hijos, y en nombre y representación del hijo con las anomalías, contra el ginecólogo y la sociedad propietaria de la clínica privada en la que fue atendida la madre. Los padres reclamaban: a) En nombre propio, 50 millones de PTA para cada uno; b) en nombre y representación del hijo con síndrome de Down, 100 millones de PTA; y c) como representantes legales de los tres hijos restantes, 20 millones de PTA para cada uno, es decir, 60 millones. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia admitió

la demanda y condenó solidariamente a los demandados a pagar una indemnización de 10 millones PTA a cada uno de los progenitores, 20 millones PTA al hijo con síndrome de Down y 5 millones PTA a cada uno de los demás hijos. La Audiencia Provincial estimó parcialmente los recursos de apelación, si bien ciñó la indemnización a la pedida por los progenitores y la rebajó a 40 millones PTA. El Tribunal Supremo, en cambio, declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto, casó la sentencia de la Audiencia Provincial y absolvió a los demandados de todos los pedimentos (véase en InDret 3/2003 el comentario de Margarita GARRIGA GORINA, *Negligencia en el diagnóstico prenatal. Comentario a la STS, 1ª, 7.6.2002*).

3. El fundamento de las demandas de **wrongful birth** *. La imposibilidad de decidir sobre la interrupción legal del embarazo*

La lectura de los hechos en la STS 18.12.2003 pone de manifiesto que se trata de un supuesto de *wrongful birth*. Por eso, sorprende que el Tribunal evite razonar en los términos típicos de una demanda de este tipo. Ello destaca especialmente en relación con el fundamento de la responsabilidad, cuya identificación condiciona los demás presupuestos de responsabilidad, desde la negligencia hasta la tipología de daños resarcibles, pasando por el nexo de causalidad.

Una característica básica de las demandas de *wrongful birth* es su estrecha conexión con la existencia del aborto y su regulación, ya que obedece a la lesión de la facultad de la madre de optar por interrumpir el embarazo, de acuerdo con los plazos y en las condiciones previstas por la ley. Eso es algo que el propio Tribunal Supremo ya reconoció en las citadas SSTS 4.2.1999 [RJ 1999\748] y 7.6.2002 [RJ 2002\5216] que, si bien rechazaron la indemnización, situaron el debate en sus justos términos al centrar el análisis en la existencia o no de relación de causalidad entre la negligencia médica y la privación a la demandante "de su facultad de optar por la interrupción del embarazo" (STS 7.6.2002, FJ 4). Por el contrario, la sentencia ahora analizada se refiere a la cuestión sólo de forma indirecta, en la exposición de los hechos. Así, al explicar las consecuencias de la negligente interpretación por el médico de los resultados de la segunda ecografía, el Alto Tribunal señala que esa negligencia conllevaba desactivar la sospecha de posibles "malformaciones (…) por lo que ya no era preciso intensificar las pruebas para su comprobación en orden a facilitar una posible (hipotética) interrupción legal del embarazo".

De los tres supuestos de aborto despenalizados por el legislador español, resulta relevante en el caso el denominado "aborto eugenésico". Así, de acuerdo con el art. 417.bis.3 CP de 1973 (todavía vigente, de acuerdo con la DD 1a) Código Penal de 1995), la interrupción legal del embarazo no resulta punible cuando "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto". Como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en la STC 53/1985, de 11 de abril, sobre la ley de despenalización del aborto, la decisión legislativa para no sancionar el aborto en los supuestos legalmente previstos, se justifica

por la necesidad de resolver el conflicto entre los diversos valores protegidos constitucionalmente, que se suscita en cada uno de los supuestos. De este modo, mientras que en el supuesto del aborto terapéutico, se encuentra en juego la vida del *nasciturus* como "bien constitucionalmente protegido" frente al derecho fundamental a la vida de la madre (Cf. art. 15 CE), en el supuesto del aborto ético el conflicto se presenta de nuevo entre el "bien" vida del *nasciturus* y la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, así como la integridad física o moral de la madre. En términos parecidos, justifica el Tribunal Constitucional la despenalización del aborto eugenésico, como vía para resolver el conflicto entre, por una parte, la vida del *nasciturus* como "bien constitucionalmente protegido" y, por otra parte, la dignidad y el libre desarrollo de la madre, reconocidos en el art. 10 CE).

4. El segundo fundamento de responsabilidad en la sentencia de 18.12.2003. Un fundamento subsidiario de las acciones de **wrongful birth**

Un análisis detallado de la sentencia que se comenta, revela que no todas las conductas negligentes de los ecógrafos se vinculan a la lesión de la facultad legal de abortar. Eso es algo que la sentencia del Tribunal Supremo intuye bien, cuando al distribuir las cuotas de responsabilidad de los diversos médicos, impone a uno de ellos, el Dr. Gisbert, una cuota tres veces superior a la que atribuye a los otros dos, Dres. Gómez y Carreras quienes, además, responden solidariamente.

La razón de esa distribución la basa el Tribunal en "la diferente entidad de las negligencias y consecuencias de las mismas". Mas, en realidad, lo que ocurre es que el fundamento de la responsabilidad de uno y otro supuesto es distinto.

De las conductas negligentes de los tres ecógrafos, sólo la del Dr. Gisbert —que practicó la segunda ecografía— tiene que ver con una acción de *wrongful birth*, porque sólo en este caso se lesionó la facultad de decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Los actos negligentes de los otros dos ecógrafos −los Dres. Gómez y Carreras−, relativos a la tercera y a la cuarta ecografías, carecían de relevancia a los efectos de ejercitar la facultad de abortar, pues los plazos para su ejercicio ya habían transcurrido. En este caso, desaparece el fundamento de las demandas de *wrongful birth*, con lo que la única alternativa posible consiste en reconducir la cuestión a otro supuesto de responsabilidad civil. El daño causado por la negligencia de los Dres. Gómez y Carreras sólo puede conectarse con el daño moral derivado del impacto psicológico que sufrieron los padres al conocer, en el momento del parto, las graves anomalías físicas que afectaban al hijo. Si, al percibir la probable existencia de una arteria umbilical única, los médicos hubieran realizado las pruebas necesarias para confirmar ese hecho y detectar la presencia de las malformaciones típicas de una patología tal, o si, como mínimo, hubieran informado a los padres de las posibles consecuencias que tenía la probable existencia de una arteria umbilical, éstos habrían podido prepararse psicológicamente para el nacimiento y atenuar así, el impacto sufrido.

En realidad, este segundo fundamento también puede cumplir una función subsidiaria en aquellas demandas de *wrongful birth* en que, si bien los padres no tuvieron conocimiento de las

malformaciones porque no se les informó de ello, la demanda no podría prosperar, bien porque no se cumplían los requisitos dispuestos para la despenalización legal del aborto, bien porque se demuestra de forma clara que, de haber tenido la posibilidad de abortar, la madre no lo habría hecho. A pesar de ello, los padres podrán ejercitar una demanda de reclamación de los daños morales derivados del shock psicológico que sufrieron en el momento del parto al conocer unas malformaciones frente a las que no pudieron preparase psicológicamente antes. Esta solución ha sido aplicada ya por algunos tribunales en Italia (*Tribunale di Perugia* de 7 de septiembre de 1998, Foro it. N. 6, Giugno 1999, p. 1804, comentada por A. PALMIERE, p. 1805),y en Francia (A. M. DUGUET, *Wrongful life; the recent French Cour de Cassation decisions*, European Journal of Health Law [EJHL], 9:139-163, 2002, p. 142).

5. La relación de causalidad

El tratamiento de los cursos causales de los ecógrafos codemandados debería haber seguido en la sentencia vías distintas. Por un lado, parece clara la conexión causal en relación con la negligencia de los dos últimos ecógrafos quienes, a pesar de incluir en los informes correspondientes a la tercera y a la cuarta ecografía la indicación "probable arteria umbilical única", ni informaron a los padres de las consecuencias de esa patología, ni practicaron las pruebas adicionales para confirmar la presencia de las consiguientes anomalías en el feto. La relación de causalidad entre esa conducta negligente y el impacto emocional que representó para los padres el nacimiento del hijo con las malformaciones inesperadas parece fuera de toda duda. Como también lo es el hecho de que, si hubieran sido informados, habrían podido preparase y atenuar, de un modo u otro, la entidad del impacto.

Mayores problemas presenta el nexo causal en la responsabilidad del médico que practicó la segunda ecografía. Por esta razón resulta más criticable que el Tribunal Supremo no profundice en la cuestión, en especial, por la vinculación que establece la propia sentencia entre la gravedad de la negligencia y la relevancia de tal información para que la madre pueda ejercer la opción —que en aquel momento todavía tiene a su disposición— de interrumpir legalmente el embarazo (FD 2 de la STS 18.12.2003). Que el citado ecógrafo actuó de forma negligente está fuera de toda duda. Lo reconoce el propio Tribunal Supremo al afirmar que "resulta inasumible que se visualizaran dos arterias cuando solo había una o que había normalidad de las extremidades cuando faltaba totalmente la inferior izquierda" (FD 2 de la STS 18.12.2003).

No obstante, una vez constatada la culpa y reconocida su relevancia "en orden a facilitar una posible (hipotética) interrupción legal del embarazo", resulta difícil comprender por qué el Tribunal no continúa esa línea argumentativa y, en cambio, salda la cuestión con una declaración tan genérica como confusa, al concluir que "existió una actuación sanitaria evidentemente deficiente al no detectarse unas anomalías de un feto, y como consecuencia se imposibilitó que el ginecólogo pudiera proporcionar a los progenitores la información adecuada a la que tenían legítimo derecho" (STS 18.12.2003, FD 3).

El razonamiento causal correcto pasaba por plantear cuál hubiese sido la decisión de la madre en el caso de haber sido informada en tiempo oportuno de las anomalías del feto. La cuestión es de capital importancia, como demuestran las tres sentencias dictadas anteriormente por el Tribunal Supremo en supuestos de *wrongful birth*. Así, mientras que la STS 6.6.1997 [RJ 1997\4610] presupone el nexo de causalidad y declara que si la madre "hubiera sabido, con el suficiente tiempo, el fracaso de las pruebas determinantes de la situación del feto dentro del límite de tiempo legal, hubiera actuado en consecuencia (…), por lo que se hubiera prestado a la intervención médica de interrupción del embarazo" (FD 3), las dos sentencias posteriores se decantan por el criterio opuesto. La STS 4.2.1999 [RJ 1999\748], entre los varios argumentos que utilizaba para rechazar la responsabilidad, consideraba que era "una simple hipótesis decir que en caso de ser informada la madre gestante habría tomado la difícil decisión de interrumpir el embarazo" (FD 5). Por su parte, la STS 7.6.2002 [RJ 2002\5216] también negó el nexo de causalidad y estableció que, en el caso, la prueba relativa a la voluntad de la madre de abortar "no está basada sino en meras conjeturas, pues como declara probado la sentencia de instancia, sin que ello se contradiga por la de apelación «la Sra. Romera en ningún momento quiso abortar»; no existe prueba alguna en autos de la que pueda deducirse que, de haber conocido la gestante el estado del feto, hubiera decidido interrumpir su embarazo. No puede afirmarse, por tanto, que exista una relación directa entre la falta de información por el médico y el que la gestante optase por poner fin al embarazo mediante el aborto" (FD 4).

En realidad, la cuestión entra de lleno en el área de la causalidad hipotética, y un buen camino para encontrar la solución correcta parece ofrecerlo la doctrina, de origen germánico, de la "conducta alternativa conforme a derecho" (*rechtmässiges Alternativverhalten)*. De acuerdo con la definición que ofrece Koziol, un daño no es imputable a su causante si, de haber actuado él mismo conforme a derecho, se hubiera producido el mismo tipo de daño y en su misma extensión. De este modo, una omisión es causa de un daño determinante de responsabilidad si la realización de una concreta conducta positiva hubiera evitado la producción del resultado, y tal conducta hubiera sido posible (véase por todos, Helmut Koziol, *Österreichisches Haftpflichtrecht,* Bd. I: *Allgemeiner Teil*, 3. A., Wien, Mainz, 1997, Rz 8/60, pp. 270-272). Aplicada a los supuestos de *wrongful birth*, esa doctrina afirmaría que a pesar de su omisión negligente, el médico no será responsable si se demuestra que, de haber proporcionado de forma diligente la información adecuada, la madre gestante tampoco habría abortado.

Sin embargo, aplicar la doctrina de la conducta alternativa conforme a derecho a los supuestos estudiados no puede convertirse en una vía fácil para exonerar a quien, con su conducta negligente, desencadenó una serie de consecuencias dañosas, en perjuicio de quien las sufrió.

Por esa razón, una correcta aplicación de esa doctrina a supuestos como el que se analiza no puede gravar a la madre con la carga de probar que, de haber podido, hubiera abortado. Es regla común en el derecho procesal, que quien alega un hecho en el proceso, soporta la carga de demostrar su existencia. Como ha reconocido la doctrina alemana, la carga de probar que de haberse observado la conducta alternativa diligente se habría producido el mismo resultado, debe recaer sobre quien alega ese hecho, que es, además, quien actuó de forma negligente (Adolf

LAUFS / Wilhem UHLENBRUCK, *Handbuch des Arztrecht*, 2. A., München, Beck, 1999, Rdn. 3-4, pp. 492-493). En el derecho procesal español, una alegación de este tipo constituye una denominada "excepción material", cuya prueba incumbe a quien la alega, es decir, al demandado (Cf. por todos, Andrés DE LA OLIVA SANTOS / Ignacio DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, *Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, pp. 264-266 y 298-302).

6. El daño indemnizable en las demandas de wrongful birth

La sentencia que se comenta otorga a los padres una indemnización de 60 millones de PTA (aprox. 361.445 €), en atención a "las expectativas de que se han visto privados los actores y la repercusión del hecho en sus vidas dada la entidad del evento producido, además del daño moral...". Se trata de una declaración muy genérica que, como suele ser habitual en la jurisprudencia española, ofrece pocas pistas sobre las concretas partidas que componen el daño indemnizado.

En realidad, volver en este punto al fundamento que justificaba las demandas de *wrongful birth* puede ofrecer criterios de suma utilidad para identificar los distintos conceptos susceptibles de indemnización y para delimitar su alcance. Desde este punto de vista, parece clara la indemnización del daño moral que deriva de los sufrimientos y padecimientos que ocasiona a los padres el nacimiento y ulterior crecimiento del hijo con malformaciones, porque es un daño que resulta directamente de la lesión de la facultad de la madre de optar por interrumpir legalmente el embarazo.

En cuanto a la indemnización de los daños patrimoniales, las dos sentencias del Tribunal Supremo sobre *wrongful birth* que hasta el momento han concedido indemnización, además del daño moral, han indemnizado los costes extras que derivan de la anomalía del hijo. Así, la STS 6.6.1997 [RJ 1997\4610] concedió una indemnización de 50 millones PTA (aprox. 300.000 €) en la que incluía "varios aspectos, como es el del impacto psíquico de crear un ser discapacitado que nunca previsiblemente podrán *[sic]* valerse por sí mismo y que pueden *[sic]* llegar a alcanzar edades medianas; lo que precisa, a su vez, una atención fija permanente y por lo común asalariada". Por su parte, ya se ha visto cómo la presente sentencia indemniza, "además del daño moral", "las expectativas de que se han visto privados los actores y la repercusión del hecho en sus vidas", expresión que, por contraposición a la genérica alusión al daño moral, debe tener una lectura económica.

Este criterio respecto al alcance del daño patrimonial indemnizable es acorde con el fundamento de las demandas de *wrongful birth.* Hay que recordar que la STC 53/1985, de 11 de abril, justificaba la despenalización del aborto eugenésico por la necesidad de resolver el conflicto que se planteaba entre, por una parte, la vida del *nasciturus* como "bien constitucionalmente protegido" y, por otra parte, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la madre. De acuerdo con el criterio del Tribunal Constitucional, "el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la

familia. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres, y especialmente la madre, agravada en muchos casos por al insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva" (STC 53/1985, FJ 10). Ese fundamento da la medida del daño patrimonial susceptible de indemnización cuando la negligencia médica ha lesionado la facultad de la madre de decidir interrumpir el embarazo por causas eugenésicas, porque con aquella negligencia, se ha obligado a la madre a soportar las "cargas excesivas" que la despenalización de aquel tipo de aborto le ofrecía la posibilidad de evitar.

Por consiguiente, en la medida en que los gastos normales de alimentación y crianza del hijo quedan fuera de ese fundamento, también se excluyen del ámbito de la indemnización del daño patrimonial en los supuestos de *wrongful birth*. Por el contrario, los gastos extras motivados por las taras físicas o psíquicas del hijo, que son precisamente aquellos que, por representar una carga excesiva para la madre y la familia, fundamentan la despenalización del aborto eugenésico, son los que deben indemnizarse en las demandas de *wrongful birth*. Entre éstos, se incluyen los gastos médicos y sanitarios derivados de la anomalía del hijo, pero también otros costes, cualquiera que sea su naturaleza, que se vinculan directamente con ella, como los gastos de adaptación de la vivienda familiar, los gastos de adquisición o adaptación de un vehículo adecuado para su transporte, la pérdida de ingresos que experimenta el progenitor que ha tenido que abandonar el trabajo o reducir su jornada laboral para atender al hijo enfermo, etc. (Miquel MARTÍN CASALS / Josep SOLÉ FELIU, *Comentario a la STS 7.6.2002*, CCJC nº 60/2002, p. 1117. En Francia, *vide* también Geneviève VINEY / Patrice JOURDAIN, en Jacques GHESTIN (Dir.), *Traité de Droit Civil. Les conditions de la responsabilité,* Paris, LGDJ, 1998, p. 16).

Una última cuestión que merece todavía ser comentada se refiere a la distribución de las cuotas indemnizatorias entre los diversos médicos condenados. La sentencia impone a uno de ellos, el que practicó la segunda ecografía, un porcentaje tres veces superior (45 millones de pesetas [*sic*]) a la cuota de la que responden −solidariamente, además− los otros dos (15 millones de pesetas *[sic]*). La sentencia justifica intuitivamente esa distribución por la "diferente entidad de las negligencias y consecuencias de las mismas". Sin embargo, como ya se ha apuntado anteriormente, la cuestión es distinta, ya que lo que en realidad ocurre es que los fundamentos de la responsabilidad del Dr. Gisbert, por un lado, y de los Dres. Gómez y Carreras, por otro, son diversos. El primero, responde de un supuesto típico de *wrongful birth* porque, como se ha visto, su conducta negligente impidió a la madre ejercitar la opción de interrumpir legalmente el embarazo, en tiempo oportuno y en las condiciones previstas por la ley. Su responsabilidad, pues, junto con la del Hospital Valle de Hebrón, debería cubrir la totalidad de los daños patrimoniales y morales mencionados anteriormente, sin que operase distribución de responsabilidad alguna con los demás ecógrafos demandados, que nada tuvieron que ver con la citada lesión y los consiguientes daños. Por el contrario, la negligencia de los Dres. Gómez y Carreras se produjo en un momento en que ya no era posible interrumpir legalmente el embarazo, por lo que su negligente interpretación de las ecografías y la consiguiente falta de información a los padres,

sólo puede dar lugar a una responsabilidad distinta, ajena a cualquier lesión de la facultad de abortar de la madre. También respecto de ese segundo fundamento, el Hospital debería responder de forma solidaria.

7. Tabla de Sentencias Citadas

Sentencias del Tribunal Supremo

Sala y Fecha	*Aranzadi/La Ley*	*Magistrado Ponente*	*Partes*
1ª, 6.6.1997	4610	Ignacio Sierra Gil de la Cuesta	Josefa P. P. *c.* Servicio Valenciano de Salud y Ramona P. T.
1ª, 4.2.1999	748	Jesús Marina Martínez-Prado	Alberto M.D., Rosalinde B. L. *c.* María Luisa O. M., Ministerio de Sanidad y Consumo, Insalud
1ª, 7.6.2002	5216	Pedro González Poveda	Tomás C. G., María Dolores R. C. *c.* Joaquín V. M. y Previsión Popular de Seguros
1ª, 18.12.2003	La Ley nº 5938/2004	Jesús Corbal Fernández	Tomás N. G., María Dolores G. *c.* Juan José G. C., Vicente-Ferrer M. H., Helena C. M., Alonso G. A., Hospital Valle de Hebrón y Institut Català de la Salut

Sentencias del Tribunal Constitucional

Sala y Fecha	*Aranzadi*	*Magistrado Ponente*
Pleno, 11.4.1985	53	Gloria Begué Cantón Rafael Gómez-Ferrer Morant

8. Bibliografía

Andrés DE LA OLIVA SANTOS / Ignacio DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, *Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000.

A. M. DUGUET, *Wrongful life; the recent French Cour de Cassation decisions*, European Journal of Health Law [EJHL], 9:139-163, 2002, p. 142.

Margarita GARRIGA GORINA, *Negligencia en el diagnóstico prenatal. Comentario a la STS, 1ª, 7.6.2002,* InDret 3/2003.

Helmut KOZIOL, *Österreichisches Haftpflichtrecht,* Bd. I: *Allgemeiner Teil*, 3. A., Wien, Mainz, 1997.

Adolf LAUFS / Wilhem UHLENBRUCK, *Handbuch des Arztrecht*, 2. A., München, Beck, 1999.

Miquel MARTÍN CASALS, *Wrongful Conception and Wrongful Birth Cases in Spanish Law: Two Wrongs in Search of a Right*, en Ulrich MAGNUS / Jaap SPIER (Ed.), *European Tort Law. Liber Amicorum for Helmut Koziol,* Peter Lang, Frankfurt a. M et alt., 2000, pp. 179-208.

Miquel MARTÍN CASALS / Josep SOLÉ FELIU, *Comentario a la STS 7.6.2002*, CCJC nº 60/2002.

Geneviève VINEY / Patrice JOURDAIN, en Jacques GHESTIN (Dir.), *Traité de Droit Civil. Les conditions de la responsabilité,* Paris, LGDJ, 1998.